

1509560-34.2020.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509560-34.2020.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509560-34.2020.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2188428/2020 - 02º D.P. AMERICANA, 12774427 - 02º D.P. AMERICANA, 103/20/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2188428 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 103/20/345 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 088/2020 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAYANE INACIO DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

DAYANE INACIO DE CAMPOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, previamente ajustada e com unidade de desígnios com JOÃO ADRIANO VIEIRA, trazia consigo e tinha em depósito, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (39 porções de CRACK - derivada da cocaína, pesando 64,21 gramas; 10 porções de COCAÍNA, pesando 6,57 gramas; e 17 porções e uma barra/tijolo de

MACONHA, pesando 472,93 gramas), que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 261/263, foi recebida em 01 de setembro de 2021 (fls. 406/408).

A ré foi citada (fls. 400).

O feito foi desmembrado em relação ao réu João (fls. 430).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas. A ré deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 450/451).

Em seus memoriais (fls. 452/463), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação da ré.

O Doutor Defensor da ré (fls. 464/467), requereu a aplicação da atenuante da confissão e da redução do tráfico privilegiado.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 226/229, 314/319, e 351/372.

É notório o perigo à incolumidade pública causado pela droga conhecida como cocaína (inclusive na forma derivada - CRACK) de alto poder viciante e que causa dependência física e psíquica, demonstrando estar plenamente caracterizada a prática delitiva.

De acordo com a doutrina:

"É tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte é quase sempre por perturbações cardíacas" (DE FRANÇA, GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p.308).

A esse respeito, a matéria publicada no conceituado jornal "Folha de São Paulo"; em 30 de dezembro de 1994:

"Cocaína é maior causa de infarto em jovens

A cocaína é responsável por quase todos os infartos do miocárdio em jovens com menos de 30 anos. A constatação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que lança na próxima semana uma campanha nacional de informação.

O objetivo é esclarecer as pessoas sobre as doenças do coração e o que se deve fazer para evitá-las. Entre os jovens, o uso da cocaína é o que mais preocupa a SBC.

"Eles precisam saber que a cocaína tem efeitos mortais no organismo", diz Claudio Buarque Benchimol, 47, secretário-geral da SBC. "Quase todos os jovens que chegam com infarto nos hospitais fizeram uso de cocaína", afirma.

É o que acontece no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, umas das mais importantes portas de entrada de vítimas de infarto em São Paulo.

O cardiologista Marcello Barduco, do pronto-socorro do Incor, confirma que entre os jovens a causa do infarto está quase sempre associada ao uso de cocaína.

O hospital registra uma média de um a três casos de infartos em jovens por mês. A

cada 24 horas, o Incor recebe uma média de cinco vítimas de infarto, idosos na grande maioria.

Não há estudos sobre os riscos nem estatísticas sobre casos de infarto por droga entre jovens. De acordo com Benchimol, o número de mortes do coração provocado por cocaína pode estar subnotificado por interferência da família. Ou mesmo pela dificuldade em se apontar a droga como causa.

De todo modo, o número de jovens que morrem por infarto é pequeno. Segundo dados da Fundação Seade, apenas 33 jovens entre 15 e 29 anos morreram de infarto do miocárdio na cidade de São Paulo no ano passado. Para se ter uma idéia, nesse mesmo período, 2.298 jovens dessa faixa de idade foram assassinados com armas de fogo e outras armas. Outros 561 morreram no trânsito.

A preocupação da SBC é com o aumento do uso da cocaína registrado nos últimos anos. "O número de usuários dessa droga vem aumentando no mundo todo", diz Benchimol.

Pesquisa feita entre estudantes de 1º e 2º graus de dez capitais brasileiras mostra que 1,2% deles já experimentou cocaína. Cinco anos atrás, apenas 0,7% dos estudantes tinham usado a droga uma vez. A pesquisa foi feita pelo Cebrid, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O perigo da cocaína é apenas um dos itens da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os médicos pretendem informar em linguagem simples como se iniciam as doenças do coração e o que pode agravá-las ou fazer com que regredam.

A hipertensão arterial e o fumo, por exemplo, são fatores de risco para um infarto. Alimentação correta, pouco estresse e exercícios físicos ajudam a manter o coração mais saudável."

E ainda:

"A quantidade necessária para provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade, ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até mesmo alucinações.

(...)

A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória".

(S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).

No mais, não há dúvida que a droga "cannabis sativa", popularmente conhecida por "maconha" causa grave dano à incolumidade pública.

Nesse sentido, o editorial do jornal Folha de São Paulo do dia 21 de fevereiro de 2000:

MACONHA E DEPENDÊNCIA

Observa-se, em São Paulo, um aumento no número de casos de pessoas que procuram ajuda médica devido a complicações relacionadas à maconha. Trata-se de uma tendência ainda não quantificada em termos científicos, mas algumas clínicas registraram um acréscimo de 20% na demanda por esse atendimento. A Universidade Federal de São Paulo inaugurou, há três semanas, um ambulatório para esses pacientes. A maconha ainda está longe de constituir um problema de saúde pública, pelo menos um problema tão grande como os 10% de dependentes de álcool na população ou os inúmeros viciados em cocaína e crack. Isso, obviamente, não é razão para fechar os olhos para a questão.

Esse fenômeno com a maconha se explica, em parte, devido a uma mudança de paradigma na psiquiatria. Até meados dos anos 80, a dependência em relação a uma droga era avaliada basicamente pela tolerância (a necessidade de usar cada vez mais para obter o mesmo efeito) e pelo nível dos sintomas de abstinência (os efeitos físicos desagradáveis provocados pela retirada da droga). Em 87, a Associação Americana de

Psiquiatria decidiu incluir também critérios psicossociais que indicassem um envolvimento sério do indivíduo com a substância para determinar se ele era ou não um dependente. Trocando em miúdos, pode ser considerado dependente todo aquele cujo envolvimento com alguma droga lhe provoca problemas sociais. Essa nova visão faz mais sentido. Afinal, o ser humano carrega em sua herança genética ou cultural uma fabulosa capacidade de ligar-se de forma patológica a determinados comportamentos, com ou sem drogas. É o caso, por exemplo, dos jogadores compulsivos. Aí, o próprio cérebro pode estar produzindo substâncias que o levam ao vício. São os chamados opióides endógenos. A literatura médica também registra episódios de dependências mais exóticas, como a de comer cenouras. Não se sabe ao certo se o beta-caroteno encontrado nesse vegetal tem potencial aditivo ou se o vício teria explicação em ritualizações. De todo modo, para a imensa maioria das pessoas, a cenoura é apenas um alimento, e saudável. Tudo está na forma como o indivíduo se relaciona com a droga, que pode ser patológica ou não, dependendo de inúmeras variáveis relacionadas à própria substância e à personalidade do usuário. O fato é que não faz mais tanto sentido falar em drogas leves. Droga é droga e muitas vezes tem consequências desastrosas. (os grifos são meus).

A autoria é indubitável.

A ré foi presa em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hédio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: “Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os Guardas Municipais declararam que realizavam patrulhamento de rotina na região quando avistaram uma mulher parada próxima a uma residência. Disseram, ainda, que a ré ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e saiu andando rapidamente, optando pela abordagem. Informaram que em revista pessoal, localizaram, no bolso da blusa, 14 porções de substância aparentando ser crack, e uma quantia em dinheiro. Indagada, a ré alegou que confirmou que estaria na traficância, e indicou que pegou a droga em uma casa que estaria pernoitando, por ser moradora de rua. Narraram, ainda, que foram até a casa, e solicitada e autorizada a entrada pela pessoa de que se identificou por

"Armando", a qual confirmou que a ré estaria pernoitando no local. Informaram, também, que durante a averiguação na casa foram localizadas outras porções de drogas (crack, cocaína e maconha), papéis com anotações e celular, além de apetrechos para o preparo da droga, como saquinhos e balança de precisão. O indivíduo, indagado, alegou que tudo pertencia a ré. Ocorre que a ré Dayane, informou que o indivíduo, na verdade, chamava-se João, sendo que Armando era seu irmão, fato posteriormente confirmado pelo réu, o qual também informou fazer parte do "Comando Vermelho". Por fim, o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada uma dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida - Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP - pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Impetração visando a absolvição do apelante por

fragilidade probatória, com base na negativa de autoria e nas contradições existentes nas versões dos policiais – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade comprovadas – Negativa de autoria isolada nos autos – Depoimentos dos policiais com pequena contradição referente ao papel do apelante no tráfico que não afeta a decisão condenatória – Testemunhas de defesa que apresentaram declarações com detalhes sequer mencionados pelo apelante, em seu interrogatório - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Criminal 0004594-74.2014.8.26.0161; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 29/08/2016)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Inclusive, julgando Apelação Criminal oriunda deste juízo, assim decidiu a 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ressalte-se que, eventuais discrepâncias entre os depoimentos não geram insegurança acerca dos fatos, pois oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada, sendo, sim, importante, verificar se, embora divergentes em detalhes mínimos, concordam os testemunhos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias mais decisivas dos fatos” (Apelação Criminal nº 00976517.3/3-0000-000, Rel. DES. FERNANDO MATALLO, 24.05.2007).

Cumprе destacar que a região onde a ré foi presa é conhecida pelo de tráfico de drogas.

A grande de tóxico apreendida, bem como sua variedade e forma de acondicionamento, somados aos apetrechos para o embalo da droga, e as folhas de caderno contendo anotações que indicam ser provenientes de atividades ilícitas (laudo de fls. 314/319), além do conteúdo do aparelho celular, com indicativo de mensagens envolvendo substancia entorpecente (laudo de fls. 351/372), evidencia a destinação de tráfico.

É certo que a simples apreensão de grande quantidade que não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, a quantidade expressiva, somada a forma de acondicionamento da substancia entorpecente, é forte indício do comércio ilícito, que aliada às demais circunstâncias servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório.

A réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos.

Ocorre que a acusada, ouvida na Delegacia (fls. 14), confessou a prática do delito, alegando a propriedade exclusiva da droga. Confirmou, ainda, que o corréu tinha livre acesso a casa.

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e

harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação da acusada é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a extrema nocividade da cocaína (inclusive na forma derivada - CRACK), exigindo especial rigor no combate ao seu tráfico, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, pela necessidade de impor ao traficante pena de severidade correspondente ao elevado risco que o comércio dessa nefanda substância acarreta à saúde pública.

A ré agiu reprovadamente com vontade livre e consciente, dirigida à prática de condutas que representam tráfico de cocaína, droga especialmente perigosa, colocando em grave perigo a saúde pública, acrescendo como circunstância a quantidade expressiva da droga, tendo como motivo o propósito de locupletamento, vale dizer, ganho fácil e espúrio.

Com efeito, segundo Damásio:

"O novo sistema penal prevê duas fases na aplicação da pena. Num primeiro momento, com fundamento no princípio da pena retributiva, fixa sua qualidade e quantidade, elaborando um juízo sobre o passado (juízo de culpabilidade), atendendo à gravidade objetiva do delito, antecedentes e personalidade do agente, sua conduta social anterior, motivos determinantes do fato e suas conseqüências." (Damásio Evangelista de Jesus, "Direito Penal", Parte Geral, 1 volume, 19ª Edição, Saraiva, 1995, p. 509)

Havendo uma graduação de penas, é evidente que a pena mínima, deve ser aplicada, por exemplo, àqueles que comercializam pequena quantidade de "maconha", tóxico muito menos grave e nocivo que a cocaína, que envolve interesses de grupos

altamente perigosos, que para a sua difusão e fabricação se organizam freqüentemente em quadrilhas, patrocinando "chacinas", segundo diariamente noticiado nos jornais. Destarte é indiscutível que a cocaína apresenta um perigo muito maior, uma maior potencialidade de dano social. Como dito acima, a cocaína freqüentemente leva à morte, além de ser porta para outros tipos de tóxicos mais graves, como a heroína, por exemplo.

A propósito, julgando feito em trâmite por este juízo, assim decidiu a Egrégia 11ª Câmara Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo relator foi o Desembargador Di Rissio Barbosa, do seguinte teor:

Comércio Clandestino de entorpecente. Pena. Exacerbação decorrente da natureza da droga, "crack", cujos efeitos são mais graves que outras drogas. Não é só admissível a exacerbação, como também recomendável por diferenciar situações díspares. (Apelação 455.718.3/1-00, 8 de junho de 2005).

Da brilhante decisão, destaco o seguinte trecho:

"...o aumento decorrente do tipo de droga, de extrema conseqüência, foi adoção que todos os Magistrados deveriam ter em mente ao calcular a pena; realmente, não se pode deferir a mesma repressão aos que se envolvem com drogas consideradas leves, pelas conseqüências que determinam, e outras consideradas pesadas, aqui com maior desprezo ao infeliz semelhante usuário".

Além disso, existe o imperativo legal do artigo 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual a quantidade e natureza da droga devem preponderar sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal no momento de fixação da pena base. Segundo o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1,956 KG DE COCAÍNA. LEGALIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) e que "[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio [...]" (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos está suficientemente fundamentada, pois as vetoriais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 1,956 kg (um quilograma e novecentos e cinquenta e seis gramas) de "cocaína". 3. O quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e elevada quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. MODIFICAÇÃO DE REGIME. PLEITO PREJUDICADO, ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. ADEMAIS, PENA SUPERIOR A 7 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cediço que, quanto à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da variedade/quantidade das drogas

(48,759kg de cocaína e 1,011kg de crack), fundamentos idôneos para majorar a pena-base e recrudesce o regime prisional. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 505.140/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Assim sendo, fixo a pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias multa, para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), reduzo a pena, retornando-a ao patamar mínimo, ou seja, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese ser a ré tecnicamente primária, considerando a quantidade de drogas apreendidas, somada a existência de apetrechos para o embalo, além da existência de mensagens pelo aparelho celular indicando intensa comercialização, o que acarreta a existência de dedicação a atividades criminosas, resta impossível a aplicação do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11343/2006.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REINCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). III - Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - In casu, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio. V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a

pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, com destaque para a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos. 2. Hipótese em que a quantidade da droga apreendida, apesar de embasar a exasperação da pena-base, não foi utilizada para definir o patamar da fração redutora, mas, sim, como um dos elementos de convicção para concluir que o paciente traficava com habitualidade e, conseqüentemente, não preenche um dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, não se dedicar a atividades criminosas. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (AgRg no HC n. 528.444/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. (...). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 613.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável à acusada, a saber, a natureza e quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, o que impossibilita a adoção de regime mais brando, segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso da Defesa – Tráfico de drogas – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas – Inadmissibilidade – Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Regime prisional mais brando – Inadmissibilidade – Acertado o regime prisional fechado para o réu, não se podendo olvidar que se trata de acusado reincidente, merecendo tratamento penal mais severo – (...) – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500257-28.2018.8.26.0613; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. A valoração negativa da quantidade de entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. Precedentes. 6. No caso, embora o paciente seja primário, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos de reclusão, as circunstâncias do crime - expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos -, sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostram-se idôneas e suficientes para o recrudescimento do regime prisional, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 613.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Além disso, nos termos do entendimento da jurisprudência (TJSP, 993.07.126969-7, 6ª

Câmara, Rel. Des. MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, j. 25.02.201), de acordo com a Lei nº. 11.464, de 28 de março de 2007, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais a análise do eventual preenchimento dos requisitos para a concessão de progressão. Se assim não fosse, não teria sentido algum outro regime a ser fixado. O legislador, ao tratar o traficante de drogas equiparado a hediondo, negou-lhe vários benefícios que a outras espécies de criminosos seriam cabíveis, como fiança, indulto, sursis, liberdade provisória etc. Assim, não faria sentido que, condenados, esses infratores recebessem pena alternativa ou cumprissem as reprimendas em regime diverso ao fechado.

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS – CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO, AINDA QUE EM SUA MODALIDADE "PRIVILEGIADA". REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. 1) A determinação de cumprimento da pena em regime inicial fechado, para condenados por tráfico de drogas, decorre de exigência expressa na Lei de Crimes Hediondos e na Lei nº 11.343/06. Decisões permissivas dotadas de efeitos "inter partes", não se registrando declaração de inconstitucionalidade "erga omnes" dos indicados dispositivos – Precedente do C. STJ – Maior rigor na repressão de crimes desse jaez, nos termos da CF/88. Compatibilidade, de qualquer forma, com a gravidade concreta dos fatos. 2) Substituição da corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade – Circunstâncias concretas a indicar a insuficiência da imposição de pena restritiva de direitos – Art. 44, III, do CP. (TJSP; Apelação Criminal 0009095-78.2015.8.26.0309; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2016; Data de Registro: 17/05/2016)

Assim também se posicionou a 7ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“No tocante ao regime prisional, deve prevalecer o fechado, por força de expressa previsão legal e o montante das penas carcerárias inviabiliza eventual substituição por restritivas de direitos. Afinal, os mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade ordeira”. (Relator Des. Roberto Mortari, j. 22.05.2014).

A ré poderá apelar em liberdade, por estar respondendo solta ao presente processo, e por estarem ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré DAYANE INACIO DE CAMPOS à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 500 (quinhentos), dias-multa, fixado no piso, como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do que dispõe o artigo 63 da Lei 11.343/2006 determino a perda dos valores e objetos apreendidos, em favor da União, devendo se proceder consoante os parágrafos do mencionado artigo após o trânsito em julgado da presente sentença.

Por fim, defiro o pedido de Justiça Gratuita, formulado pela Defesa a fls. 467, nos termos do artigo 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. I. C.

Americana, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA